



SENTENCIA

Expediente : 5234-2023
Demandante : Procurador Público del Ministerio de Defensa
Demandado : Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y otros
Materia : Impugnación de resolución administrativa

RESOLUCIÓN NÚMERO DIECISEIS

Lima, 5 de diciembre de 2024.-

I. ANTECEDENTES

La demanda contenciosa administrativa interpuesta por el **Procurador Público del Ministerio de Defensa** contra el **Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y los Vocales de la Segunda Sala del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Johan León Florián, Vanessa Luyo Cruzad y María Rosa Mena Mena**; con el Expediente Administrativo acompañado en autos.

Pretensión del Proceso:

Resulta de autos que, mediante escrito de demanda de fecha 11 de mayo de 2023 el Procurador Público del Ministerio de Defensa interpone demanda contenciosa administrativa teniendo como pretensión:

Principal: Se declare la nulidad de la Resolución N° 000411-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA del 06 de febrero de 2023, expedida por la Segunda Sala del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que declaró fundado el recurso de apelación presentado por Ernesto Alonso Cabral Mejía y en consecuencia ordena al CCFFAA entregar la información pública solicitada por dicho ciudadano, mediante formulario de fecha 28 de diciembre de 2022.

Fundamentos de la demanda:

La parte demandante sostiene:

1. Con fecha 28 de diciembre de 2022, el ciudadano Ernesto Alonso Cabral Mejía presentó formulario por correo electrónico solicitando la siguiente información “tipo y cantidad de armamento y municiones utilizadas por las Fuerzas Armadas el 15 de diciembre de Huamanga (Ayacucho); entre el 11 y 14 de diciembre de Andahuaylas (Aurimac) y el 16 de diciembre de Pichanaki (Junin), en el marco del D.S. 143-2022-PCM”; dando respuesta mediante Oficio N° 153-CCFFAA/SG/UAIP de fecha 11 de enero de 2023, en el cual se le indicó que es inviable atender su requerimiento; siendo apelado y resuelto por la Resolución N° 000411-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA del 06 de febrero de 2023 declarando fundada la apelación y Ordena al CCFFA, entregue copia de Tipo y cantidad de armamento y municiones utilizadas por las Fuerzas Armadas el 15 de diciembre de Huamanga (Ayacucho); entre el 11 y 14 de diciembre en Andahuaylas (Aurimac) y el 16 de diciembre en Pichanaki (Junin), en el marco del D.S. 143-2022-PCM.
2. Indica que el derecho de acceso a la información pública no es absoluto, pues los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 27803 establecen excepciones.
3. En el presente caso, en sede administrativa, el CCFFAA ha manifestado que la petición del administrado no resultaba atendible, por ser una información con carácter de secreta, según el artículo 15 del TUO de la Ley 27806, lo que posteriormente, corrigió y precisó, indicando que su pedido estaba dentro del supuesto previsto en el literal e del numeral 1 del artículo 16 de la citada Ley, dado que, la documentación e información está relacionada con el éxito de los objetivos trazados para el restablecimiento del orden público, mantenimiento del Estado de Derecho y subsistencia del orden democrático, en el marco de un Estado de Emergencia Nacional del Perú, lo que debió ser ponderado por la demandada.
4. La demandante ha acreditado que la información se encuentra clasificada como secreta, reservada, con la Resolución de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas N°107-CCFFAA/SG/FRAI del 14 de marzo de 2023.
5. La demandada tampoco motiva cuando señala que la información señalada estaría relacionada con la vulneración de derechos humanos o de las

Convenciones de Ginebra de 1949, no precisando cuál es el supuesto; y de haberlo, bajo su lógica y se habría determinado mediante sentencia judicial firme las responsabilidades de los miembros de las Fuerzas Armadas por vulneración de los derechos humanos, cuando recién se está en etapa de diligencias preliminares ante el Ministerio Público.

Tramitación:

Por Resolución Número Uno de fecha 15 de mayo de 2023, se admite a trámite la demanda debiendo entenderse contra el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública corriendo el traslado respectivo.

Por Resolución Número Dos de fecha 14 de noviembre de 2023, se integra al proceso en calidad de Litisconsorte necesario a Ernesto Alonso Cabral Mejía.

Contestación de demanda

Por escrito de fecha 07 de mayo de 2024, se apersona al proceso el Procurador Público del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, contesta la demanda negando y contradiciéndola en todos sus extremos, alegando:

1. El demandante ha obviado que toda documentación que obra en el archivo o dominio estatal es de carácter público para conocimiento de la ciudadanía, por ser de interés general, conforme lo ha subrayado el Tribunal Constitucional en el Fundamento 5 de la sentencia recaída en el Expediente N°4865-2013-PHD/TC.
2. La demandante no ha probado la clasificación de reservado, ya que, la clasificación de información secreta o reservada tienen determinadas formalidades, como que la misma haya sido aprobada por el titular del sector o pliego, o funcionario designado por este, y que la misma se encuentre consignada en el registro correspondiente, y en el cual se especifique la fecha de la resolución de clasificación, la denominación de la información clasificada y su código, siendo que ninguna de dichas formalidades ha sido acreditadas por la entidad.

Por Resolución Número Seis de fecha 08 de mayo de 2024, se tiene por contestada la demanda y se requiere el expediente administrativo.

Por Resolución Número Ocho de fecha 23 de mayo de 2014, se tiene por recibido el expediente administrativo.

Por Resolución Número Nueve de fecha 17 de setiembre de 2024, se declara rebelde al litisconsorte necesario pasivo Ernesto Alonso Cabral Mejia.

Por Resolución Numero Diez de fecha 17 de setiembre de 2024, se declaró la existencia de una relación jurídica procesal válida entre las partes y, por ende, saneado el proceso, fijándose los puntos controvertidos, se admiten los medios probatorios que allí se indican. Tramitada la causa corresponde emitir sentencia.

II. FUNDAMENTOS

Fines del Proceso Contencioso Administrativo.

PRIMERO: Conforme a lo previsto en el artículo 1° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, la Acción Contencioso Administrativa (Proceso Contencioso Administrativo) a que se refiere el artículo 148° de la Constitución Política del Perú tiene por finalidad, de un lado, el control jurídico por el Poder Judicial de la legalidad y constitucionalidad de las actuaciones de la Administración Pública sujetas al derecho administrativo; de otra parte, busca una efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados.

Puntos controvertidos

TERCERO: En el caso de autos, en concordancia al punto controvertido fijado en la Resolución Número Diez de fecha 17 de setiembre de 2024, se declro como punto controvertido, determinar si corresponde declarar la Nulidad total de la Resolución N° 00411-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA del 06 de febrero de 2023.

Antecedentes Administrativos.

CUARTO: De la revisión del expediente administrativo que obra en autos, se observa lo siguiente:

- Con Formulario de Acceso a la Información Pública (Fs. 37) de fecha 26 de diciembre de 2022 el señor Ernesto Alonso Cabral Mejía, solicita *“tipo y cantidad de armamento y municiones utilizados el 15 de diciembre en Huamanga (Ayacucho); entre el 11 y 14 de diciembre de Andahuaylas (Apurímac) y el 16 de diciembre de 2022 en pichanaki (Junín) en el marco del DS 143-2022-PCM.*
- Por Oficio N° 153-CCFFAA/SG/UAIP del 11 de enero de 2023 de fojas 21 el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas la demandada denegó la solicitud de información con Código OTD/SG N° 0000420323, en aplicación del artículo 15 del Texto Único Ordenado de la Ley 27806.
- Con fecha 23 de enero de 2023 de folios 11 a 20 vuelta, el administrado Ernesto Alonso Cabral Mejía presenta recurso de apelación contra la respuesta denegatoria de acceso a la información pública.
- Con fecha 31 de enero de 2023 (Fs. 42-44) obra el Informe Ampliatorio N° 002-2023/JCCFFAA/D-3/DAI.
- Por Resolución N° 000411-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA del 06 de febrero de 2023, de folios 45-54 se declaró fundado el recurso de apelación interpuesto por Ernesto Alonso Cabral Mejía, ordenando al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que entregue la información solicitada por el recurrente, bajo apercibimiento de que la Secretaría Técnica de esta instancia, conforme a sus competencias, remita copia de los actuados al Ministerio Público en caso se reporte su incumplimiento, declarando por agotada la vía administrativa.
- Por Resolución N° 000885-2023/JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA del 17 de marzo de 2023 de folios 68-70 desestima el pedido de aclaración de la Resolución N° 000411-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA, y corrige el artículo 1 de la parte resolutive de la citada resolución administrativa, y mantiene subsistentes los demás extremos de la referida resolución.

Marco Normativo.

QUINTO: *Derecho de libertad de información y derecho de acceso a la información pública.*

El inciso 5 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú establece que “Toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones

que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional”.

Asimismo, el artículo 3 inciso 1 del Texto Único Ordenado de la Ley 27806 toda información que posea el Estado se presume pública, salvo las excepciones que expresamente establece la ley.

Análisis de la Controversia.

SEXTO: La accionante tiene como pretensión que se declare la nulidad de la Resolución N° 000411-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA del 06 de febrero de 2023 por cuanto atenta contra la seguridad y defensa nacional, y no se ha motivado en modo alguno que la información solicitada se encuentre incurso dentro del supuesto establecido en el artículo 18 de la Ley 27806; por tanto, la información no puede ser otorgada por estar dentro de las excepciones señaladas en el artículo 15° y 16 inciso e del Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia, en tanto dicha información se encuentra relacionada a la seguridad y defensa nacional prevista en el artículo 163 de la Constitución Política de Perú.

SÉPTIMO: Al respecto, el artículo 163 de la Constitución Política del Perú señala:

“Artículo 163.- El Estado garantiza la seguridad de la Nación mediante el Sistema de Defensa Nacional.

La Defensa Nacional es integral y permanente. Se desarrolla en los ámbitos interno y externo. Toda persona, natural o jurídica, está obligada a participar en la Defensa Nacional, de conformidad con la ley.”

“Artículo 165° de la Carta Magna.- Las Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. Tienen como finalidad primordial garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. Asumen el control del orden interno de conformidad con el artículo 137° de la Constitución.”

Asimismo, el **Artículo 137** de la Carta Magna, entonces vigente, señala:

“El Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar, por plazo determinado, en todo el territorio nacional, o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, los estados de excepción que en este artículo se contemplan:

1. Estado de emergencia, en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación. En esta eventualidad, puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado f del mismo artículo. En ninguna circunstancia se puede desterrar a nadie.”



En el presente caso, la demandante alega que la resolución administrativa impugnada no se ha pronunciado sobre sus razones para denegar la información solicitada. De la revisión de la resolución administrativa materia de Litis, se aprecia que la demandada indicó que la información aludida como clasificada no reúne los requisitos previstos en el artículo 21 del Reglamento de la Ley de Transparencia, pues no acredita con resolución alguna que dicha información sea reservada o secreta, por ende, concluye que corresponde entregar la información al administrado; empero, no ha ponderado que dicha información ha sido clasificada por la demandante como secreta/reservada y por ende se encuentra dentro de los supuestos de excepción del TUO de la Ley 27806, debiendo prevalecer lo previsto en el artículo 163 de la Constitución Política del Perú, que señala que el Estado garantiza la seguridad de la Nación mediante el Sistema de Defensa Nacional, y se desarrolla en los ámbitos *interno* y *externo*, así como el artículo 165 y lo previsto en el artículo 137 inciso 1 de la Carta Magna que señala, que “el Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar, por plazo determinado, en todo el territorio nacional, o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, los estados de excepción que en este artículo se contemplan: 1. Estado de emergencia, en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación”, debiendo de considerar que conforme al artículo 3 inciso 1 del TUO de la Ley de Transparencia el derecho al acceso a la información pública no es un derecho absoluto.

Sin perjuicio de lo señalado, la demandante ha ofrecido en el procedimiento administrativo, la Resolución Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas N° 107-CCFFAA/SG/FRAI del 14 de marzo de 2023, que aprueba la documentación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y su Anexo, que será clasificada como secreta, reservada y confidencial en mérito a las excepciones de acceso a la información dispuesta en la Ley 27806, dispone en su artículo 2 que el funcionario responsable de acceso a la información, proceda a la inscripción de la presente resolución del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en el registro correspondiente; formalidad, que a criterio de este juzgado, no puede ser tomado como base para desconocer el carácter de secreto o reservado de la información solicitada; en todo caso, corresponde establecer la responsabilidad administrativa de los funcionarios responsables que no verificaron su registro oportuno, en tanto ello se había ordenado de manera antelada a la solicitud de acceso a la información pública materia de Litis de fecha 26 de diciembre de 2022.

La citada resolución administrativa impugnada, señala: “En dicho contexto, conforme al artículo 18 de la Ley de Transparencia en el supuesto que la información solicitada (en el presente caso, sobre el armamento y municiones utilizados el 15 de diciembre en Huamanga (Ayacucho), entre el 11 y 14 de diciembre en Andahuaylas (Apurímac) y el 16 de diciembre de 2022 en Pichanaki (Junín)) se encontrara relacionada a la vulneración de derechos humanos o

de las Convenciones de Ginebra de 1949, realizada por cualquier personal, en cualquier circunstancia, la misma no puede ser clasificada como reservada, secreta o confidencial”; cabe señalar que en efecto, según el artículo 18¹ de la Ley de Transparencia, no corresponde aplicar las excepciones previstas en los artículos 15 y 16 cuando la información de acceso público esté relacionada la violación de derechos humanos o las Convenciones de Ginebra de 1946; también lo es que, el solicitante en su recurso de apelación (Fs. 17-18 del expediente administrativo) ha señalado que la Fiscalía de la Nación del Perú ha dispuesto el inicio de investigación preliminar contra la Presidenta de la República, Dina Boluarte, el Presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, el Ministro del Interior, Víctor Rojas, el Ministro de Defensa Jorge Chávez, el ex presidente del Consejo de Ministros Pedro Angulo y el ex ministro del Interior Cesar Cervantes por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidas durante las protestas en los meses de diciembre de 2022, y enero de 2023 en los departamentos de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho, entre otras denuncias, sobre las cuales, en tanto no haya pronunciamiento definitivo a nivel del Ministerio Público o el Poder Judicial, este juzgado no puede afirmar la existencia de vulneración de los derechos humanos por el uso arbitrario de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, por ende, dicho artículo 18 del TUO de la Ley de Transparencia no corresponde aplicarse.

OCTAVO: En ese contexto normativo, se aprecia que existe cierta limitación al acceso a la información en el sector público cuando estas se traten de información reservada o secreta, los mismos que son considerados como excepciones al ejercicio de derecho de acceso a la información pública, tal como precisa la norma glosada, esto en total concordancia con el artículo 163 de nuestra Constitución Política, buscando con ello garantizar la seguridad de la personas y cuya revelación pondría en riesgo la integridad territorial, la subsistencia del sistema democrático, material bélico, accesorios que podrían poner en riesgo los planes de defensa, de las fuerzas armadas como de la policía nacional del Perú.

¹ Art. 18 del TUO de la Ley de Transparencia: *“Las excepciones señaladas en los puntos 15 y 16 incluyen los documentos que se generen sobre estas materias y no se considerará como información clasificada, la relacionada a la violación de derechos humanos o de las Convenciones de Ginebra de 1949 realizada en cualquier circunstancia, por cualquier persona. Ninguna de las excepciones señaladas en este artículo pueden ser utilizadas en contra de lo establecido en la Constitución Política del Perú.”*



NOVENO: Como ya se señaló, si bien la entidad demandada considera que las resoluciones que deniegan el acceso a la información deben estar debidamente motivadas, también es cierto que la demandada pondera la seguridad nacional (bien público) sobre el derecho de acceso a la información (derecho de un particular); es por ello que la disposición de la demandada a brindar información pública solicitada, es por ello la necesidad de que esta se encuentre debidamente sustentada; por lo que, el acto administrativo impugnado se encuentra viciando según el numeral 1 del artículo 10 de la Ley 27444; siendo ello así, la demanda debe ser amparada, debiendo emitir nuevo acto administrativo.

III. PARTE RESOLUTIVA

Por las consideraciones precedentes, la Magistrada del Decimosexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, impartiendo justicia expide el siguiente fallo

Declarando **FUNDADA** la demanda interpuesta por el **Ministerio de Defensa** contra el **Ministerio de Justicia y Derechos Humanos**.

En consecuencia:

Se declara la **NULIDAD** de: la Resolución N° 000411-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA del 06 de febrero de 2023; corresponde a la administración emitir nuevo pronunciamiento, dando el estricto cumplimiento a las garantías del debido procedimiento, señalados en la presente sentencia, dentro de plazo de 15 días hábiles de consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia, bajo apercibimiento de multa compulsiva y progresiva.

NOTIFICÁNDOSE a las partes procesales. –